

1501016-24.2022.8.26.0266

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME DE SIQUEIRA PASTORE

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

LUIZ FERNANDO DOS SANTOS SILVA e outro

Juiz de Direito: Dr. GUILHERME DE SIQUEIRA PASTORE

Flavio Eduardo da Silva e Luiz Fernando dos Santos Silva, qualificado nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006, porque em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara da Comarca de Itanhaém

Avenida Rui Barbosa, 867

Centro - CEP 11740-000, Itanhaém-SP

Fone: (13) 2102-1511 - E-mail: itanhaem2@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501016-24.2022.8.26.0266

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

LUIZ FERNANDO DOS SANTOS SILVA e outro

Juiz de Direito: Dr. GUILHERME DE SIQUEIRA PASTORE

Flavio Eduardo da Silva e Luiz Fernando dos Santos Silva, qualificado nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006, porque em 05/07/2022, por volta das 15h53min, na Rua dos Lírios, no bairro Nossa Senhora do Sion, nesta cidade e Comarca de Itanhaém, supostamente traziam consigo e tinham em depósito, para entrega a terceiros, 82 porções de crack e 193 porções de maconha, sem autorização legal. Os acusados foram presos em flagrante e, em audiência de custódia, tiveram a prisão convertida em preventiva, sendo na mesma oportunidade recebida a denúncia e realizada a citação, com a nomeação de defensora dativa (fls. 82/88). Após a resposta à acusação (fls. 141/142), foi ratificado o recebimento da denúncia (fl. 151/152).

Em audiência de instrução, ouvida uma testemunha e interrogados os réus.

Superada a fase de diligências, foram realizados debates orais, em que o Ministério Público pediu a condenação dos réus nos termos da denúncia, valorando-se a natureza e a quantidade de drogas desfavoravelmente na primeira fase da dosimetria, em relação a Flavio, e na terceira, em relação a Luiz, de modo a afastar a figura privilegiada para ambos e, não obstante a confissão, a imposição do regime fechado para início de cumprimento das penas; ao passo que a Defesa postulou a fixação das penas no mínimo legal para o réu Luiz Fernando, por ser primário, de bons antecedentes; e o reconhecimento da confissão espontânea em favor do réu Flávio. Este o relatório, passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória comporta integral acolhida, uma vez que a prova submetida ao crivo do contraditório judicial demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, bem como a sua autoria.

A materialidade foi comprovada pela apreensão das drogas, regularmente documentada

em auto próprio (fls. 16/17), com a correspondente constatação provisória (fls. 18/19), e pelo subsequente laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 144/146), que descreve o exame do material apreendido por métodos apropriados e conclui, ao final, tratar-se das substâncias entorpecentes e psicotrópicas descritas na denúncia, que têm o uso proscrito por figurarem nas listas F1 e F2 da Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (aplicável por força do art. 66 da Lei n.º 11.343, de 2006). A destinação da droga guardada à traficância se deduz com absoluta clareza dos parâmetros elencados no art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, notadamente em vista da quantidade de droga e a forma do seu acondicionamento, manifestamente incompatível com a posse para consumo pessoal; e das condições em que se desenvolveu a ação, que, assim como a autoria, foram elucidadas pela prova oral.

O policial civil Luciano Cesar, ouvido em juízo sob o compromisso legal, descreveu minuciosamente a dinâmica da venda de drogas no local dos fatos, conhecida como "Biqueira da Lírios", em que a via pavimentada segue até uma área de mata, na qual se realiza habitualmente a atividade do tráfico em uma clareira, valendo-se de cercas que dificultam o acesso; e na qual há sempre olheiros, que tornam a incursão policial inviável sem o emprego de viatura descaracterizada e disfarces. Narrou, ainda, a diligência realizada no dia dos fatos, em paralelo a um inquérito já em tramitação para apuração da dinâmica do tráfico no local, e o encontro do réu Luiz Fernando recepcionando os usuários, recebendo o dinheiro e, na sequência, se embrenhando na mata, de onde retornava e devolvia algo. Afirmou que, quando Luiz Fernando entrou na área de mata para buscar droga, conseguiu acompanhá-lo e avistou o corréu Flávio em uma clareira, com uma mochila nas costas, cercado de outras pessoas, que aparentavam ser usuários de drogas. Disse que, após conseguir transpor a cerca, Flávio se debateu brevemente, mas acabou por se render; e Luiz Fernando retornou para a área externa, onde foi abordado pelo policial João Paulo.

Cuida-se de testemunha compromissada e insuspeita, uma vez que nada indica tivesse motivos para incriminar falsamente os réus. No exercício regular da atividade de polícia investigativa, presenciou a exteriorização da prática criminosa, razão pela qual é testemunha por excelência e seu relato é imprescindível ao descobrimento da verdade. Atribui-se ao seu depoimento, portanto, à míngua de disposição legal em contrário, o mesmo valor de outra testemunha compromissada; não superior, mas tampouco inferior.

Os réus, por sua vez, confessaram o delito. De um lado, Flávio afirmou que era usuário de drogas, devia dinheiro para a "loja" e, ao chegar para comprar drogas, pediu para permanecer ali; então os responsáveis pela venda o deixaram com a sacola até que retornassem. Já Luiz Fernando disse que atuava como olheiro, em troca de drogas. Indagado, esclareceu que, além de recepcionar os usuários, buscava as drogas para alguns, que não conseguiam atravessar.

Em suma, conquanto tenham tentado minimizar a relevância do seu envolvimento com a venda de drogas no local, os réus admitiram integralmente os fatos, tal como descritos na denúncia e confirmados pela testemunha policial, fornecendo assim embasamento seguro para a condenação, nos termos da denúncia.

Passo a dosar as penas que aos réus serão impostas.

Ao crime do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343, de 2006, são cominadas, em abstrato, as penas de reclusão e multa, cumulativamente.

Para a determinação inicial da quantidade de pena aplicável, as circunstâncias do art. 59 do Código Penal não chegam a ser desfavoráveis aos réus. Preponderam, no entanto, por força do que dispõe o art. 42 da Lei de Drogas, a natureza e a quantidade das drogas, que no caso dos autos são vetor negativo, em vista da apreensão na casa das centenas de porções, perfazendo meio quilograma de massa, destoante da realidade local; e da notória nocividade dos entorpecentes apreendidos, especialmente a cocaína, para a saúde pública, considerando a elevada aptidão para produzir dependência química e estimular a agressividade.

Ainda que o egrégio Superior Tribunal de Justiça tenha revisado o entendimento anteriormente firmado em embargos de divergência, de modo a possibilitar a valoração dessas circunstâncias tanto na primeira quanto na derradeira fase da dosimetria (3ª Seção, HC 725.534, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 24/04/2022),

no caso dos autos a natureza e a quantidade de drogas não são suficientes a caracterizar o envolvimento com o meio criminoso, de modo que mais adequada se mostra a consideração nesta fase.

A combinação desses fatores recomenda incremento de 1/3 (um terço) sobre o mínimo legal, fixando as penas-base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na sequência, incide em relação ao réu Flávio a agravante genérica da reincidência (art. 61, inc. I, do Código Penal), uma vez que registra condenação definitiva por crime anterior (processo n.º 0000858-82.2018.8.26.0266, desta 2ª Vara, referente a fato ocorrido em 07/02/2018, com trânsito em julgado em 30/04/2018), e as penas nele impostas foram extintas em 06/11/2020 (processo de execução n.º 0002043-91.2018.8.26.0158, também desta Vara), conforme consta às fls. 70/71.

Ela se compensa, todavia, com a atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea "d", do Código Penal), na forma do entendimento de longa data firmado pela jurisprudência, inclusive em recurso especial representativo de controvérsia, julgado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência." (3ª Seção, REsp 1.341.370/MT, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

Quanto ao réu Luiz, aplica-se somente a atenuante, que reduz as penas iniciais em 1/6 (um sexto), resultando em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, as penas provisórias do réu Flávio se tornam definitivas, ausentes outras circunstâncias a considerar, dado que reincidente.

Em relação ao réu Luiz, por outro lado, é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que é primário, de bons antecedentes, e que não há demonstração concreta de dedicação habitual à traficância nem de envolvimento com o meio criminoso. Ausentes circunstâncias negativas a balizar a redução, o redutor incide no patamar máximo, de 2/3 (dois terços), e torna definitivas as reprimendas em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado para o réu Flávio, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal; mas para o corréu Luiz Fernando se aplica o aberto, uma vez que a primariedade e a extensão da reprimenda apontam para a sua adequação, não bastando as circunstâncias judiciais do caso concreto, conquanto desfavoráveis, a impor regime mais gravoso, ressalvada eventual necessidade de regressão.

Inviáveis, não obstante, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, tendo em vista as circunstâncias negativas, que não abonam a suficiência das medidas alternativas para a consecução das finalidades preventiva e repressiva da pena.

Ausente demonstração de condição socioeconômica abastada por parte dos réus, arbitro o dia-multa no mínimo legal, de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacionalmente unificado vigente ao tempo da prática do delito, atualizado pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais divulgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até o efetivo pagamento.

Por essas razões, julgo procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia para CONDENAR os réus:

1) Flavio Eduardo da Silva, brasileiro, solteiro, servente, portador do RG n.º 53.691.819, CPF 429.420.568-78, filho de Maria Luciene da Silva, nascido em 28/05/1997, natural de São Paulo/SP, por infração ao art. 33, caput, da Lei n.º 11.343, de 2006, às penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado na forma da fundamentação;

2) Luiz Fernando dos Santos Silva, brasileiro, solteiro, portador do RG n.º 56.772.097, CPF 502.451.598-60, filho de Jose Fernando da Silva e Adriana dos Santos Silva, nascido em 19/01/2001, por infração ao art. 33, caput c.c. § 4º, da

Lei n.º 11.343, de 2006, às penas de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado na forma da fundamentação.

Condeno os réus, ainda, ao recolhimento das custas do processo, no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), ressalvada a suspensão de exigibilidade que decorre da gratuidade que ora lhe defiro. Anote-se.

Faculto ao réu Luiz Fernando, ante a desproporção entre a segregação cautelar e o regime de cumprimento da pena que lhe foi imposta, o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se incontinenti alvará de soltura clausulado.

Quanto ao réu Flavio, inalteradas as considerações expostas por ocasião da conversão da prisão em flagrante em preventiva, notadamente quanto ao risco de reiteração criminosa evidenciado pela reincidência, denego o recurso em liberdade. Recomende-se na prisão em que se encontra.

Decreto o perdimento do celular apreendido (fl. 16), considerando que o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes é mandamento de criminalização insculpido no art. 243, parágrafo único, da Constituição da República; com base no qual, no julgamento do recurso extraordinário n.º 638.491/PR, julgado em 17/05/2017, foi firmada pelo Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, a tese de que o perdimento deve ocorrer "sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade (...) ou qualquer outro requisito" (tema 647).

Transitada em julgado, intime-se o réu Luiz Fernando para audiência admonitória e expeçam-se guias de recolhimento definitivas em relação a ambos, bem como certidões individualizadas das penas de multa, e abra-se vista ao Ministério Público.

Também após o trânsito em julgado, comunique-se à Autoridade Policial, para destruição das amostras de drogas guardadas para contraprova, nos termos do art. 72 da Lei n.º 11.343, de 2006, bem como para destruição das anotações do tráfico e providências para a destinação do celular apreendido.

Após, feitas as anotações e comunicações necessárias, em especial ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD e ao colendo Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição da República, arquivem-se os autos.

Proferida em audiência, saem os presentes intimados.

Itanhaém, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006